壹、婚生子女

一、要件 (§1061、1063Ⅰ)

1.生父、生母須有婚姻关係

2.子女係妻分娩所生 (SC28渝上1445例) ⇒ 若登記他人子女為自己子女且無分娩事實者非婚生子女

3.於婚姻中受胎 (受胎期間：§1062) (35院解3321、SC 19上750例、21上3000例) (SC 94.06.21第七次民庭会议：受胎自子女出生日起算)

4.通：婚生子女須為其母之夫之血統 (史、鼎、胡、李宜琛、戴、棋) ⇒ 須有生父血統

↳林：條文中無法推得，故僅須具備前三要件 ⇒ 於否认之訴確定前仍推定為婚生子女

二、婚生推定 (§1063Ⅰ)

1.未同JP§772Ⅰ明文生父推定，惟解釋上仍應认可推定為父之子女 ⇒ 有婚生及父性推定之双重功能 (林)

2.妻所生子女無法受婚生推定 (SC 29渝上2046例)

3.同居事實

(1)必要說 (曹、胡)

(2)非必要說：保护子女 (林、戴、史、棋、25院1426、33院2773)

4.87刪§987、994再婚待婚限制 ⇒ 重複推定 (ex: 3/4 甲乙離，3/4 甲丙結，11/4 出生 ⇒ 再婚181日後，離婚302日內)

(1) Ger§1593：先推定後夫，於後夫否认之訴確定後推定與前夫親子关係

(2) TW法無明文 ⇒ 家事§65
- 配偶與前夫互為被告
- 子女、生母以現夫及前夫為共同被告，提起子女確定生父之訴

三、婚生否认 (§1063Ⅱ、Ⅲ)

1.否认子女之訴 (家事§63Ⅰ)

(1)原告適格

A.夫

(A)未成年人因結婚具行為能力(舊法) ⇒ 有訴訟能力 (民訴§45)

(B)夫受監护宣告 ⇒ 監护人代理，但妻代訴訟行為難期待 ⇒ 依利害关係人聲請或職权選任程序監理人 (家事§15)

B.妻

(A) N74：不得提起 / JP、Swiss 不承认妻之否认权 / FR 限糾正為目的始肯定

(B) 林：擴大婚生否认人範圍对子女不利 ⇒ 妻行使否认权以損害子女為主要目的 ⇒ 法院應以濫用否认权為由，駁回其訴

C.繼承权受侵害之人 (家事§64)：夫妻一方於法定期間前或內死亡者，繼承权受侵害之人得提起之

SC106台上72

(2)被告適格 (家事§63)

A.未起訴之夫、妻與子女為共同被告 (家事§63Ⅰ)

B.應為被告之人均死亡 ⇒ 檢察官為被告 (家事§63Ⅲ後)

2.否认推定生父之訴

(1) 原告適格

A、子女（SC 23上3473例、75台上2071例 反对／J587⇒96立法、SC96台上2278）

(A) 7岁以上按家事§14Ⅱ即有程序能力

(B) 依舊民訴§596Ⅱ準用585Ⅰ or 家事§15Ⅱ 法院得职权選任程序監理人

B、繼承权受侵害之人（家事§64）

(2) 被告適格

A、家事§63Ⅱ：以推定之生父為被告

B、家事§63Ⅲ：推定之生父死亡者以檢察官為被告

3. 訴之性質：形成之訴（家事§48Ⅰ）

4. 確认親子关係之訴（家事§67）vs 婚生否认之訴

(1) 否定说：前者具補充性質，須与既有之訴訟類型无法解決方得提起（林、魏大喨）

(2) 肯定说：使身分明確⇒有確认利益，应做实体上審查（沈冠伶、SC 105台上700）

(3) 不受家事64之除斥期間限制（学说、SC 105台上700）

四、否认原因：能証明子女非婚生子女（§1063Ⅱ）｜子女発育情況，妻是否非於婚姻中受胎、夫不能為性行為、人种（性状）、父孩的腹、DNA

五、時效性質：形成权⇒除斥期間（J587、通）

六、起訴期間

1、~96：1年／96~§1063Ⅲ本文：2年

2、成年後子女2年內（§1063Ⅲ但）

3、繼承权受侵害之人：死者死亡後1年（家事§64Ⅱ）

貳、任意认領

一、§1065Ⅱ：視為婚生，无須认領

二、§1065Ⅰ：經生父认領，視為婚生。經生父撫育者，視為认領

三、性質

1. 觀念通知说（事实之通知）：向对方通知自己业已认识其与非婚生子女有血緣关係而已，通知後所發生之各种法律效果，乃為民法概括所賦予（楊）

2、特別意思表示说：身分行為之意思表示（戴）

3. 单独行為说（通）：屬意思表示，但无須被认領人同意⇒生父对非婚生子女承认其為父子

4、无区分实益说（林）：依§1070用語觀之，似认係意思表示⇒均以事实上父子女关係存在為前提⇒区別实益不大

四、形成权，但行使无須以訴為之（SC 63台上1796例）

五、通：不要式行為，戶籍法雖有登记⇒僅為証明方式，非认領形式要件

六、屬身分行為 ⇒ 基於身分關係安定性，不得附條件或期限（通）

七、史、棋、戴、振、琛：舊戶籍法有遺囑認領 ⇒ 允許遺囑認領 / 林：§1199 遺囑係人死亡生效 ⇒ 違反不得附款原則，且戶籍法因民法未規定已刪除此條
⇒ 應認此種認領已不要式，載於遺囑書上亦可生效而已

八、撫育：不限於教養，亦不問生母是否曾與生父同居（23院1125）

1. 史、戴炎輝：主觀主義 ⇒ 生父須有以該子女為自己子女之意思為撫育，始得視為認領

2. 棋：客觀主義 ⇒ 有撫育事實即應擬制為業已通知對於有親子關係，可以作沉默之確認或宣言，不問內心意思（林）

九、撫育費得預付 ⇒ 若預付則可認有認領（SC 44台上1167例）

十、妻作為家屬受家長即胎兒之生父扶養時，表面上妻受扶養，實質上胎兒亦受扶養 ⇒ 可認同生父撫育者（21院735）

十一、要件（§1065 I）

1. 被認領人須為非婚生子女（SC 96台上2811）

(1) 胎兒可認領（§7）（實、通）

(2) 已死亡之非婚生子女

A. 否定說：民法未明文，死者無人格，流弊甚大（胡、鼎、戴、高鳳仙、許澍林）

B. 肯定說：法未禁止、單獨行為且保障血親之利益，不影響繼承 ⇒ 若濫用可認無效（史、趙、棋、林）

(3) 亂倫子：不能準正，得認領（36院解3329）

(4) 推翻推定可由生父認領（37院解4082、SC 98台上704，反對：SC 29上1832例—廢）

2、認領人為生父：須血緣，認領係身分行為，不得由他人代理，只須有意思能力為已足，不以行為能力為必要

十二、無效（舊民訴§589／家事§67）

1、無意思能力之認領

2、認領人非被認領人之生父（SC 86台上1908例）

3、他人代理之認領

4、被認領人係婚生子女（33院解2773）⇒ 生父、生母結婚視為婚生後無須認領（§1064）

5、違背遺囑方式（棋、史）/ 林：認領應不要式 ⇒ 縱無效仍對已生效之認領無影響

十三、撤銷（§1070 不得撤銷）

1、不得任意撤銷說（鼎、胡、李宜琛、趙）：受詐欺、脅迫仍可行使撤銷權

2、若有血統絕對不得撤銷說：如有血緣詐欺，不妨提起認領無效主張認領無效（戴、史、棋）

3、林：§1070 排除總則，若無血緣自屬無效，無須撤銷 ⇒ 96~§1070但 徒增適用上困擾（通）

4、戴、少數說：肯定 §1070但

十四、否認（§1066）

1、舉證肯定說：須證明有反對之事實（戴），第三人則不得否定（批評：無否認認領之訴，且課予生母及子女舉證責任）

2、無須舉證說（棋、史）：否認屬形成權，無須舉證（林）⇒ 否認後應由父提起確認親子或收養關係存在之訴 並負舉證責任（家事§67 I）

參、強制認領（§1067Ⅰ）

一、認領之訴（家事§66）之性質

1. 給付訴訟說：認領屬意思表示⇒以為意思表示請求給付（姚瑞光、楊建華）

2. 確認訴訟說：認領屬事實通知或觀念通知，僅重血統之事實，不在乎有無認領，對應認領而不認領之生父得以判決代替認領（棋、戴）

3. 形成訴訟說：創設父子女關係，有對世效（史、陳計男、林、振）

4. 林：96修正前宜採給付訴訟說，96後因得向繼承人或社福主張（§1067Ⅱ），應為給付之訴（SC 98台上94）

二、原告

1. 非婚生子女：7歲以上有程序能力，得獨立起訴（家事§14Ⅱ）

2. 生母與其他法代

(1) 法定代理說：身分行為不許意定代理但許法定代理⇒代非婚生子女提出（戴炎輝、戴東雄）

(2) 固有權利說（棋、戴）：舊民訴§596Ⅰ但解釋，生母或法代有扶養義務⇒認領可減輕⇒有訴之利益，本於固有權利為之

(3) 折衷說（史、胡）：生母請求係固有權利之行使，法代代表生母為之（胡）
法代代表子女（史）

三、被告：生父

1. 舊法：限生存之生父（23院1125）

2. 96~：家事§66

四、不負抗辯（~96 §1068）

五、請求權 消滅

1. ~96 §1067Ⅱ：子女成年後2年、生母及其他法代子女出生後7年，現已刪除，無時效

2. 拋棄

(1) 肯定說：子女、生母得足夠利益則不必認為無效（棋）

(2) 否定說（林、李宜琛）：無判決、立法精神，且有關§1115Ⅰ扶養義務順序

六、原因

1. 大清民律草案親屬§92、14民律草案親屬§161、17親屬法草案§42Ⅰ不列舉原因採概括主義

2. 19~96 §1067Ⅰ：列舉4事由 $\xRightarrow[法]{修}$ 96~ §1067Ⅰ：客觀主義（概括主義）

肆、效力

一、發生時點

1. 溯及出生時（§1069本文）

2. 繼承權

(1) 不取得說（史、戴炎輝、棋、台北地院98重家訴21、100重訴312、高院99重家上7、SC 103台上2519）

(2) 折衷說：目的性限縮§1069但
- 嗣後發現說（SC 100台上452）
- 對外債權說（高院100重家上更(一)3）
- 遺產分割說（高院101重家上50）
- 遺產分割說+嗣後發現說（SC 103台上618、台中地院104家訴136、桃園地院106重家訴16）

(3) 林：取得，否則架空死後認領

3、胎兒

(1) 溯及出生時，但以非死產者為限（史、模、胡）

(2) 林：遺腹子女⇒对生父若採前說則无從發生血親关係⇒應採认領時生效說

二、第三人既得权之保护；不得訴請撤銷婚姻（胡、林）

三、親子关係之發生

1、雙方均獲得繼承权（§1138），互負扶養义务（§1114①）

2、生母、後順位扶養之人因溯及效可对生父依§179請求已支付之扶養費（史、戴、模）

3、行使权利义务準用離婚（§1069-1 $\xrightarrow{準用}$ §1055～1055-2）

伍、準正（§1064）

一、要件

1、受準正者係非婚生子女

(1) 廣义說（不限子女出生前結婚）（曹、史、林）：不因认領、準正修文而有不同⇒婚姻不及181日雖不受婚生推定，但仍受準正

(2) 狹义說（限子女出生前結婚）（胡、戴、模）

2、生父与生母結婚

(1) 非生父應為繼父，无法準正

(2) 无效則无準正可能⇒禁婚親（SC 30渝上454例）

(3) 撤銷因无溯及效（§998）⇒準正效力不受影响

二、生效時點

1、父母結婚時說

2、溯及子女出生時說（通）：準正應同认領⇒類推§1069